

妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(1) 犯罪情节较轻；(2) 有悔罪表现；(3) 没有再犯罪的危险；(4) 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

笔者认为，在上述适用缓刑的条款中，“悔罪表现”在相当程度上能够反映出行为人的 人身危险性及改造的难易程度，更是衡量“没有再犯罪危险”的 内在因素和实质条件。如果行为人没有任何悔罪表现，则不能排除其有再犯罪 的风险，也就是说悔罪表现在判断有无再犯罪危险方面起着不可或缺的重要作用，也应是适用缓刑的重要考量指标之一。何谓悔罪表现，如何认定“悔罪表现”，目前尚没有明确的司法解释，也没有清晰的规范定义。笔者认为，悔罪表现的通俗理解应是行为 人对于自己实施的犯罪行为所表现出的懊恼、自责的 心态与行为。司法实务一般认为悔罪表现就是认罪、悔罪，认罪是悔罪的前提 和基础，即首先要对自己的犯罪事实认可，认识到所犯 罪行的危害性，内心才 能对犯罪行为表示悔过，愿意接受司法机关的处理。而“认罪”的本质应是行 为人对自己行为方式、后果以及行为本身恶性的一种内省的心理态度，即承认 犯罪事实，并对其行为的违法性、社会危害性和应受惩罚性产生合乎 行刑目的 的认识，行为人只有“认罪”，才能深刻感知所保护的 社会关系的神圣性和法 律的严肃性，进一步形成遵守法律的自觉性，这也是考察行为人适用缓刑是否 会有再犯罪危险的 内在要求。因此，对于行为人适用缓刑，应严格审查行为是 否具备认罪悔罪的行为表现，主要包括：在刑事侦查、起诉、审判过程中主动 投案、坦白自己的主要犯罪事实、积极退赃、认罪认罚、向被害人道歉等。也 有一些学者对悔罪构成进行分析

，认为应包括以下五个方面的要素：(1)承认 犯罪行为已经发生；(2)承认自己的行为构成犯罪；(3)承认自己对犯罪行为负责；(4)表示悔过或悔恨；(5)保证将来不再犯罪。上述5个方面，前3个 要素构成认罪，后2个要素构成悔罪。参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的 相关规定，适用缓刑的前提包括本身符合缓刑条件，对于认罪认罚也是能够适用缓刑的情形之一。因此，在理论和司法实务中，在行为人“拒不认罪”的情

况下，一般不应考虑适用缓刑。

本案中，虽然一审判决认定和某某主动向公安机关投案，如实供述，成立自首，并予以减轻处罚。但综合考量和某某归案后至庭审中的表现，其均辩称自己的行为是代开发票，不构成虚开发票罪。笔者认为，和某某对行为性质进行辩解虽成立自首，但并不能认定为“认罪”，行为人在一审、二审诉讼中始终强调其行为属于代开发票，其实质是在主要事实方面做无罪辩解，也表明其自始至终并没有认识到虚开发票行为的社会危害性和刑事违法性，不具有悔罪表现，不符合适用缓刑的法定条件。但，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百零一条第一款的规定，在审理被告人提出的上诉案件中，不得对被告人的刑罚作出实质不利的改判，其中该条第四项规定“原判对被告人宣告缓刑的，不得撤销缓刑或者延长缓刑考验期”，即在检察机关没有抗诉的情况下，遵循“上诉不加刑”原则，不能在二审程序中径直作出撤销缓刑的裁判。

编写人：南宁铁路运输中级法院 张红娟

三、刑事证据

54

被告人零口供、被害人前后陈述矛盾、证据单一， 如何根据现有证据认定构罪

—— 蒋某强奸案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖南省邵阳市中级人民法院(2023)湘05刑终395号刑事裁定书

2. 案由：强奸罪

【基本案情】

被告人蒋某，男，1970年12月2日出生。因涉嫌犯强奸罪，于2023年2月8日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。被告人蒋某系被害人曾某继父，曾某的母亲周某某与蒋某均系再婚，曾某随周某某、蒋某一起共同生活。周某某与蒋某再婚后分别于2017年生育了大儿子蒋某2、2021年生育了小儿子蒋某1。自2018年以来，蒋某经常趁与曾某独处之机，多次对曾某实施强奸。2023年2月4日晚，被害人因寒假作业未写完，遭到母亲周某某训斥，母亲让其随蒋某去某镇陪伴两个弟弟。在此情形下，被害人将其被蒋某性侵的事实告诉了周某某，后被害人在亲生父母的陪同下来到医院进行检查，确认被害人处女膜破裂，

医生向公安机关报警。具体犯罪事实如下：

1. 2018年下半年的一天，在某宾馆3楼一房间内，被告人蒋某趁曾某的母亲周某某外出买菜之机，对曾某实施强奸行为。

2. 2022年9月或10月的一天晚上，在某幼儿园4楼的一房间内，被告人蒋某趁曾某熟睡之机，对曾某实施了强奸。

3. 2023年1月20日晚上，被告人蒋某带上两个儿子及被害人曾某一同在某酒店××房间住宿，蒋某待两个儿子都睡觉之后，对曾某实施了强奸。

【案件焦点】

现有证据能否认定被告人蒋某犯强奸罪。

【法院裁判要旨】

湖南省新宁县人民法院经审理认为：被告人蒋某利用继父身份，长期、多次对不满十二周岁的继女实施强奸，情节恶劣，其行为构成强奸罪。公诉机关的指控成立。被告人蒋某对未满十二周岁且有共同家庭生活关系的继女、多次实施强奸，应当从重、从严惩处。因被告人蒋某经营和管理幼儿园，应依法禁止其从事密切接触未成年人的工作。根据被告人蒋某的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第一项、第三十七条之一、第五十五条第一款、第五十六条，《中华人民共和国未成年人保护法》第六十二条之规定，判决：

被告人蒋某犯强奸罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年；禁止被告人蒋某从事密切接触未成年人的工作。

一审宣判后，被告人提出上诉。

湖南省邵阳市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点是现有证据能否证明被告人蒋某的行为构成强奸罪？本案

被告人拒不承认犯罪事实，被害人三次陈述前后矛盾，被害人母亲表示其教唆被害人陷害被告人。通过分析案发、报案情况，对全案证据进行审查，反复斟酌两段通话录音中当事人的情绪和内容，现场查看被害人陈述的案发地，从而对被害人前后矛盾的三份陈述作出研判，认为本案能够形成完整证明体系，可以认定案件事实。

一、本案案发自然、报案经过自然，符合正常事件的发展规律

2023年2月4日晚，被害人因寒假作业未写完，遭到母亲周某某训斥，母亲让其随蒋某去某镇带两个弟弟。在此情形下，被害人将其被蒋某性侵的事实告诉了周某某，后被害人在亲生父母的陪同下来到医院进行检查，确认被害人处女膜破裂，医生向公安机关报警。本案中，被害人基于害怕被送至某镇带弟弟而与蒋某朝夕相处，而向母亲倾诉其遭到蒋某侵害，本案案发自然；被害人亲生父母基于各种原因未成功报警后，医生基于职业原因向公安机关拨打报警电话，报案经过自然；曾某、蒋某、周某某之间均没有矛盾，案发前也未发生争吵，可以排除诬告陷害等异常因素的介入。

二、在案证据来源合法，可信度较高，可以作为定案依据

在案证据中，被害人在案发后第一时间被带至侦查机关进行两次询问，侦查机关对被害人的取证程序合法。被害人在公安机关的两次陈述前后内容基本一致，对案发时的时间、地点、过程和细节描述比较清晰、具体。被害人的陈述与证人证言、录音资料，以及新宁县人民医院诊断证明等其他证据相互印证。

三、被告人关于无罪的辩解依法不能成立

经查，被害人陈述被蒋某性侵时间跨度长，侵害次数多，地点变换频繁，而指控的三起事实即初次、处女膜破裂、案发前的某宾馆客房，三起事实的时间、地点对被害人均具有深刻的记忆。结合医院诊断结论，被害人处女膜欠完整，多点陈旧性裂伤，符合被多次性侵所造成的后果。分析被害人在案发当天及次日的两次陈述均自然、稳定，指向明确，记忆清晰，描述较为详细，就被害人尚未满十二周岁年龄而言，如非亲身经历，不会产生如此深刻的记忆。而被害人第三次陈述系案发后第八天在母亲的安排下主动前往公安机关，有人为

因素干扰，且被害人的第三次陈述对被强奸的事实全部予以否认，对处女膜破裂原因的陈述时间模糊、地点不详，陈述处女膜系凳脚插伤的理由牵强。比较而言，被害人的前两次陈述更符合其亲身经历的感知，可信度更高。关于前两起事实中性侵的地点，被害人两次陈述和录音问话中对其在某酒店××房间被性侵的陈述稳定、一致，在某幼儿园四楼被性侵的事实则有现场勘查笔录和证人证言佐证。关于录音材料中被害人陈述其在幼儿园大厅旁边教室的厕所内被蒋某性侵，经现场查看，符合被害人陈述的情形，虽该起事实未被指控，但被害人陈述的事实，印证了录音内容的真实性。关于曾某、唐某文的证言，侦查机关对两人的取证程序合法，两位证人证言陈述的事实相互吻合。对比周某某躲避侦查机关调查，阻挠曾某报警与曾某强烈要求追究蒋某犯罪行为的主观意愿，可以排除曾某与周某某事前共谋陷害蒋某。且本案案发突然、医生当班与被害人就诊系偶然事件、被害人的伤害后果是客观事实，曾某与唐某文医生不存在互相串通的情形。关于周某某敲诈勒索蒋某之父50万元，证人仅通过旁听他人电话内容，未核实对方的身份，不足以证明周某某有敲诈勒索行为，且证人所反映的事实与本案指控的事实无关。关于周某某证言，周某某从知晓曾某被性侵时的情绪；到知晓医学检查结果后的纠结；再到曾某接受询问时陪同的周某某现场情绪失控并干扰曾某作证；最后周某某持续躲避侦查机关调查取证，周某某在整个过程中情绪、态度的变化符合常人的处事特征。而周某某在案发七天后在民警多次做工作的情况下的证言系深思熟虑和趋利避害的结果。结合周某某与蒋某再婚后的夫妻感情、家庭融洽程度、经济基础，周某某没有教唆曾某陷害蒋某的理由和意义。

本案中，被告人辩称其对被害人没有实施强奸行为，但依据对在案证据的分析及被害人的年龄、心智的成熟度分析，在案证据能够形成完整的证据链条，可以证实被告人的行为构成强奸罪。

既往性犯罪法体系中的强奸罪和强制猥亵、侮辱罪均无法适用此类案件，使得具有法益侵害性的上述行为在刑法上存在处罚漏洞：一方面，该类人员在对该类女性自小进行教育时便使其认为与自己发生性关系是“理所应当”的情

形下，很难判断这种“自愿”是否“违背未成年女性意志”。另一方面，在实践中因该类行为隐蔽性的特征，常会陷入举证不能的困境，若按照“存疑有利于被告”的原则，不仅该类女性的权益不能得到救助，也将损害司法的公信力。故《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将该类人员与该类女性发生性关系纳入规制的范围，旨在补足法律规范缺失、刑法治理不足的问题，以实现未成年女性权益的全覆盖保护。

编写人：湖南省新宁县人民法院 陈松柏 汪方方

强制猥亵案被告人翻供的审查认定

—— 林某强制猥亵案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02刑终4号刑事附带民事裁定书

2. 案由：强制猥亵罪

【基本案情】

被告人林某在其经营的“遇某”理发店趁给被害人赵某洗发、赵某不敢反抗之机，对赵某实施如下三次猥亵行为：第一次、第二次分别为2022年1月21日傍晚、2022年2月春节期间，林某在给赵某洗发时，对赵某进行猥亵。第三次为2022年2月20日19时，林某在给赵某洗发时，对赵某进行猥亵。2022年2月21日，民警在“遇某”理发店将林某抓获归案，前期如实供述犯罪事实，后期翻供。事发后，赵某与班主任联系，告知其被猥亵，班主任遂与赵某家长取得联系，赵某母亲李某某报警。另查明，2008年1月12日为农历2007年12

月5日；厦门市中小学寒假从2022年1月21日开始，2022年1月21日为农历12月19日；2022年2月1日为农历正月初一。

【案件焦点】

被告人林某翻供否认猥亵被害人能否成立。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：被告人林某翻供不能成立，应认定林某对赵某实施了强制猥亵行为。(1)根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条的规定，被告人林某在侦查阶段前期供述其猥亵被害人三次，但在侦查阶段后期、审查起诉和庭审时均对猥亵行为予以否认，否认的理由是其害怕被害人家属报复或是因为害怕公安机关民警，此翻供理由均不能成立。林某在侦查前期所作有罪供述是其真实意思表示。经过查看讯问的同步录像，林某所作有罪供述均是其自己陈述经过，公安机关侦查人员不存在恐吓、诱供等影响林某真实表达意思的行为。在讯问过程中，讯问人员态度和缓，也没有存在被施加压力导致林某害怕的情形。林某所述因为害怕被害人家属报复而不得不承认猥亵事实，更是与日常生活经验相违背，该辩解本院不予采信。因此，林某翻供理由不能成立。(2)被告人在狭窄空间内给被害人洗头时对未成年女性实施猥亵行为，应认定为强制猥亵。强制猥亵行为的手段不仅包括暴力和猥亵，还包括利用被害人来不及反抗等特定时机对被害人实施的猥亵行为。在本案中，被害人是在校初中生、涉世未深，而且，正常人在洗发时处于放松和无防备的状态，因存在肢体接触，还对对方寄予信任。因此，在面对被告人突然将手伸向内衣，且男女力量、年龄都存在差距的情况下，被害人不仅来不及反抗，也不敢反抗。即使是在案发后，被害人与班主任老师的沟通中反复强调其很害怕，更担心报警后可能导致的不利后果。因此，本院认定被告人林某利用特殊时机以其他方法对被害人实施了强制猥亵行为。

福建省厦门市海沧区人民法院判决：被告人林某犯强制猥亵罪，判处有期徒刑

徒刑三年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2022年2月22日起至2025年2月21日止。)被告人林某应于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人赵某医疗费、检查费、交通费共计人民币2212.76元。驳回附带民事诉讼原告人赵某的其他诉讼请求。

一审宣判后,李某提出上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为:上诉人林某以其他方法强制猥亵女性,其行为已构成强制猥亵罪。原判认定事实清楚,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。裁定:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第九十六条的规定,被告人庭前供述和辩解存在反复、庭审中不供认的情况下,需要对全案被告人供述与辩解进行审查,并结合庭审翻供事由及全案证据材料进行判断、认定。

一、翻供事由合理性审查

实践中,庭审翻供事由以刑讯逼供为主,应对讯问程序进行合法性审查。讯问必须遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》、司法解释及其他规范性文件的 规定,依照法定程序进行,即讯问是否在刑事立案之后进行,讯问时间、地点、讯问人的身份、人数以及讯问方式是否符合相关法律规定。具体而言,讯问是否违反规定较长时间持续进行(是否存在疲劳讯问)、讯问过程中是否保证犯罪嫌疑人 的饮食和休息时间、讯问是否 在规定的办案场所之外进行,讯问人员是否少于两人,等等。本案被告人翻供事由为“害怕被害人家属报复或是因为害怕公安机关民警”。经过查看讯问的同步录像,林某所作有罪

供述均是其自己陈述经过，在讯问过程中，讯问人员态度和缓，不存在被施加压力导致林某害怕的情形，亦无恐吓、诱供等影响林某真实表达意思的行为。

二、被告人供述和辩解实质性审查

对被告人供述和辩解进行合法性的形式审查，还应当对内容进行全面、实质审查。证据规则固然重要，但根据经验法则判断是否符合常识常理常情也很重要。实践中，侦查阶段，犯罪嫌疑人往往在意志最薄弱的时刻心理防线被突破，所以其在案件初始阶段的认罪供述大多数情况下是真实的。本案被告人林某在侦查阶段前期供述其猥亵被害人三次，但在侦查阶段后期、审查起诉和庭审时均对猥亵行为予以否认。林某所述因为害怕被害人家属报复而不得不承认猥亵事实，更是与日常生活经验相违背，因此，林某翻供理由不能成立。

三、全案证据综合性审查

除审查翻供事由合理性及被告人供述和辩解内容外，还应结合全案的证据体系，看被告人供述与物证、书证等客观性证据等是否相互印证，是否指向明确。强制猥亵行为的手段不仅包括暴力和猥亵，还包括利用被害人来不及反抗等特定时机对被害人实施的猥亵行为。本案中，被害人是在校初中生、涉世未深，而且，正常人在洗发时处于放松和无防备的状态，因存在肢体接触，还对对方寄予信任。因此，在面对被告人突然将手伸向内衣，且男女力量、年龄都存在差距的情况下，被害人不仅来不及反抗，也不敢反抗。因此，应当认定被告人林某利用特殊时机以其他方法对被害人实施了强制猥亵行为。

综上，被告人翻供情形复杂，必须以慎之又慎的态度，客观理性地对待翻 供，牢固树立证据裁判意识及程序意识，根据翻供的内容对被告人供述与辩解 进行综合审查判断予以认定。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 芦絮 张鑫

四、程 序

56

重疾罪犯收监执行审查应建立专家会商机制

—— 林某帮助信息网络犯罪活动案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市永春县人民法院(2023)闽0525刑更2号收监执行决定书

2. 案由：帮助信息网络犯罪活动罪

【基本案情】

罪犯林某因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑，交付监所执行后，其于2022年6月28日以身患高血压3级、糖尿病2级等疾病为由申请监外执行，某女子看守所向本院通报罪犯林某病情。本院于2022年9月9日作出(2022)闽0525刑更5号暂予监外执行决定书，决定对罪犯林某暂予监外执行。

暂予监外执行期间，某社区矫正管理局书面建议本院对罪犯林某收监执行。本院于2023年5月18日立案后，依法组成合议庭进行审查，并于2023年5月18日发函某医院调查罪犯林某的病情与不规则服药的情况。某医院出具了《关于林某病情情况说明》，内容为该院相关专家对病人的联合会诊诊断意见，是基于患者检查化验有时达到高血压3级极高危诊断标准，但受病人不规则用药、

不规范治疗、不配合治疗的影响。患者于2023年2月、5月住院期间，尿微量蛋白、肾功能正常，糖尿病病情好转。两次住院时间间隔短，与挂床治疗无异常，并且病情大相径庭，故作出不属于《暂予监外执行规定》的意见。本院于2023年6月5日发函某社区矫正管理局调查罪犯林某复查的过程等。某社区矫正管理局复函说明，某社区矫正管理局委托某医院对罪犯林某进行病情复查，2023年2月初某医院安排林某住院治疗。2月24日14点40分，某医院医务科告知，林某住院病情复查期间多次未在病房内。司法所工作人员立即通知林某住院期间必须住在病房内，并配合医生做好病情复查相关检查。在本院询问调查中，林某陈述其病情相较于之前泉州医学高等专科学校附属人民医院出具的罪犯疾病诊断证明书记载的病情更加严重。其一直按时服药、配合治疗。其确实未在医院住院，但医院开的检查项目均有去检查，因家中有小孩需要照顾，其与医院和司法局沟通，司法局让其自己决定。其未及时取药是由于之前的药量还有剩余61天，就没有去医院取药。

另查明，罪犯林某申请监外执行后，于2022年8月8日经泉州医学高等专科学校附属人民医院诊断，患有高血压病3级（很高危）、高血压性心脏病、2型糖尿病、高血压性视网膜病变、颈动脉粥样硬化等。在2023年3月9日的病情复查中，某医院对林某的病情诊断为：（1）高血压病3级（极高危）；（2）高血压性心脏病；（3）高血压性视网膜病变；（4）高血压并微量蛋白尿；（5）2型糖尿病；（6）右锁骨下动脉斑块；（7）轻度贫血；（8）乙肝病毒携带者。患者平时不规则服药，建议门诊规范治疗。

【案件焦点】

罪犯林某暂予监外执行期间的病情变化情况是否与其不配合治疗存在关联性，是否符合不得监外执行的情形。

【法院裁判要旨】

福建省泉州市永春县人民法院经审理认为：社区矫正对象应当按照有关规定和社区矫正机构的要求，定期报告、遵纪守法、接受监督管理，暂予监外执

